



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/53/2020
מס' בקשה: 8/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

- | | |
|---|-------------|
| 1 | נוי שרון |
| 2 | ירקוני מרב |
| 3 | ירקוני יורם |
| 4 | ארנון אורן |
| 5 | נוימן אידה |
| 6 | נוימן צבי |
| 7 | שמעון סימה |

תובעים

באמצעות ב"כ: עו"ד י. פרימס ואח'
דרך הים 16, חיפה
טל': 04-8388332 פקס: 04-8381401

נגד

- | | |
|---|----------------|
| 1 | צדוק עודד אריה |
|---|----------------|

נתבעים

באמצעות ב"כ: עו"ד מוטי כהן ואח'
הבנקים 11, חיפה
טל': 077-4244373 פקס: 072-2123330

- | | |
|---|-----------------|
| 2 | באומן אורן יעקב |
|---|-----------------|

באמצעות ב"כ: עו"ד שרגא בלזר ואח'
הרצל 4, ת.ד. 44581, חיפה
טל': 04-8622565 פקס: 04-8671471

פסק דין

7. השאלה העומדת לפתחי היא האם עומדת לנתבע מס' 1 הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית ברוב הדרוש לצורך הרחבת דירתו בהתאם להיתר בניה מס' 51/3716/08 שעניינו תוספת בניה לדירה קיימת בקומה א' הכוללת שיפור מיגון, שינויים פנימיים וחיצוניים, ומרפסת זיזית.

רקע כללי-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מס' תיק: 8/53/2020
מס' בקשה: 8/54/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. עסקינן בבית משותף הנמצא ברח' זרובבל 15, חיפה, ומזוהה כחלקה 58 בגוש 10767. הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים והוא מונה 9 דירות (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעים הם בעלים של 6 מתוך 9 דירות בבית, והנתבעים הם בעלים של שתי דירות אחרות בבית. הבעלים של הדירה הנותרת לא היה צד להליך.
3. בכתב התביעה עותרים התובעים למתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים לבנות בהתאם להיתרי הבניה שקיבלו מהטעם שהם נעדרים הסכמותיהם של בעלי הדירות בבית בשיעור שנקבע בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").
4. בישיבה שהתקיימה בתיק ביום 21.5.20 ויתרו הצדדים על הבאת ראיות בתיק והסכימו כי פסק הדין יינתן על בסיס המסמכים שהוגשו לתיק.
5. ביום 16.6.20 הודיע נתבע מס' 2 כי הוא מסכים למתן צו מניעה קבוע כנגדו, אשר ימנע ממנו לבצע את עבודות הבניה שאושרו לו ללא צו להוצאות. ב"כ התובעים הצהיר לפרוטוקול ביום 21.5.20 כי ימליץ למרשיו להסכים למתן צו מניעה קבוע כנגד הנתבע מס' 2 ללא חיוב בהוצאות. משלא התקבלה כל תגובה של התובעים להודעת הנתבע מס' 2 מיום 16.6.20, ניתן בזאת צו מניעה שיאסור על נתבע מס' 2 או מי מטעמו לבנות בהתאם להיתר הבניה שקיבל כל עוד לא תהיה באמתחתו הסכמה מפורשת של יתר בעלי הדירות בבית בשיעור הקבוע בחוק המקרקעין.
6. כעת נותר לי אפוא להכריע בתביעה בעניין הנתבע מס' 1 (להלן: "הנתבע").
טענות התובעים בקצירת האומר-
7. בידי הנתבע היתר בניה שקיבל מאת רשויות התכנון לאישור תוספת בניה לדירתו. תוספת הבניה אמורה להתבצע ברכוש המשותף של הבית, תוך פגיעה בקניינם של יתר בעלי הדירות, ומשכך, היא מחייבת קבלת הסכמת 75% מבעלי הדירות אשר צמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף בהתאם לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין שכותרתו: שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה". הבקשה להיתר כוללת "שיפור מיגון", ואין מדובר בבניית ממ"ד ולכן גם לגבי מרכיב זה בבקשה להיתר נדרשת הסכמה של 75% מבעלי הדירות שלהם צמוד 2/3 מהרכוש המשותף. היות שהתובעים הם בעלים של 6 מ-9 דירות בבית נעדר הנתבע הסכמות בשיעור הקבוע בסעיף דלעיל.
8. התובעים סבורים כי הדבר הנכון מבחינה בטיחותית ותכנונית הוא לבצע פרויקט תמ"א בבית. לטענתם, מדובר בבית בן למעלה משישים שנים אשר קיימים בו סדקים רבים וככל שהזמן עובר מצבו מחמיר. בנוסף, בגלל האופן בו הוא בנוי, לא ניתן לבצע הרחבה של דירה בכל הדירות אלא רק בחלקן ועל כן נוצר אי שוויון לגבי חלק מהדירות. כמו כן, בגלל המבנה של הבית ההרחבות המבוקשות עתידות לגרום להפרעה לדירותיהם.
9. מסמך ההסכמות עליו נסמך הנתבע הינו מסמך הסכמה "מובנה" שנוסח על ידי עיריית חיפה למתן היתר מתאריך 26.11.13, קרי לפני יותר משש שנים. מכאן עולה שאין בידי הנתבע כל מסמך המאשר ומעיד על הסכמת הדיירים לביצוע עבודות הרחבה בדירתו. לצורך הדיון אף אם יקבע כי בשנת 2013 ניתנה הסכמה של חלק מבעלי הדירות בבית להרחבה של הדירה, הרי שהסכמה זו אינה רלוונטית עוד נוכח הזמן הרב שחלף ושינוי הנסיבות הכולל שינוי/החלפת בעלים בדירת הנתבע ורצון בעלי הדירות בית לבצע פרויקט חיזוק מכוח תמ"א 38 בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/53/2020
מס' בקשה: 8/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בשעה שמכר מר צבי אופיר, הבעלים הקודם של דירת הנתבע (להלן: "אופיר"), את דירתו לנתבע בשנת 2017, היתר הבנייה שניתן לו בשנת 2013 היה פג תוקף וזאת זמן רב קודם למכירה, ואופיר ידע כי רוב בעלי הדירות בבית שינו את דעתם והגיעו למסקנה שעדיף לבצע פרויקט תמ"א בבניין. הנה כי כן, גם אם ניתנה בעבר הסכמה להרחבת דירת אופיר הרי משעה שהוא זנח את בקשתו להרחבת הדירה והעדיף למכור אותה אין עוד תוקף להסכמה זו. היות שבמועד בו נמכרה הדירה לנתבע לאופיר לא הייתה שום הסתמכות על ההסכמות שניתנו לו בשנת 2013, הרי שהנתבע אינו רשאי לטעון כי הסתמך על אותן הסכמות. יתרה מכך, בהסכם המכר שנחתם בין אופיר לנתבע אין כל התחייבות ו/או מצג של אופיר כלפי הנתבע בעניין ההסכמות.

11. לאור האמור לעיל, מבוקש לקבל את התביעה, ולחלופין, מטעמי זהירות, ככל שיקבע כי ניתן לבצע את הבניה המבוקשת ע"י הנתבע מתבקש למנות שמאי, בהתאם לאמור בסעיף 71ג(א) לחוק, על מנת שיישום את תשלומי האיוון המגיעים בגין כך לתובעים בעבור ניצול אחוזי בנייה ע"י הנתבע בשיעור העולה על חלקו היחסי.

טענות הנתבע בתמצית-

12. בשנת 2017 רכש הנתבע את דירתו מאופיר ו"נכנס לנעליו" תוך שהוא מסתמך על ההסכמות שקיבל אופיר לבניה שהתכוון לבצע. מיד לאחר הרכישה הגיש הנתבע בקשה להיתר בנייה דומה לבקשה להיתר בניה לה קיבל אופיר הסכמות.

13. טרם שרכש הנתבע את דירת אופיר הובא לידיעתו דבר קיומו של פסק דין שניתן ע"י כב' המפקחת הבכירה צ. פינגבוים בתיק מס' 252/15 ממנו עולה כי זכות אופיר להרחבת דירתו בדרך של בניית ממ"ד ובניית מרפסת זיזית אינה שנויה במחלוקת. הנתבע הסתמך על קביעה זו.

14. התובעים לא הוכיחו מתי פקעה ההסכמה שנתנו לאופיר. מתן הסכמה לאופיר לבנות וסירוב לבנייה דומה ע"י הנתבע באותה דירה מהווה שימוש לרעה בהליכים משפטים והתנגדות שאינה בתום לב.

15. התובעים לא הציגו כל מסמך המלמד על כך שהחלו לפעול לקידום תמ"א 38, והם אינם מצביעים על האופן שבו תיפגע דירה כלשהי בבית מבניית הנתבע. טענתם לעניין רצונם להתקשר בפרויקט תמ"א 38 לבניין נטענה בעלמא.

16. יש לדחות מכל וכל את ניסיונם חסר תום הלב של התובעים להתנער מההסכמה שניתנה על ידם בשנת 2013 ולראותה כמחייבת ובת תוקף.

17. **דיון והכרעה-**

18. אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה כפי שיפורט להלן:

חוסר תחולתו של הכלל בדבר "השתק עילה/פלוגתא"-

19. לטענת הנתבע יש להורות על סילוק התביעה על הסף מחמת מעשה בי-דין אשר יש בו כדי ליצור השתק פלוגתא. לטענתו, הפלוגתא בתיק זה זהה לפלוגתא שנדונה בפני המפקחת על רישום מקרקעין צ. פינגבוים בתיק תביעה מס' 252/15 (להלן: "ההליך הקודם"), בהליך הקודם התקיים דיון לגופה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/53/2020
מס' בקשה: 8/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של הפלוגתא, וההתדיינות שם הסתיימה בהכרעה מפורשת שהייתה חיונית לצורך פסק הדין שם. התוכנית מושא ההליך זהה לתוכנית הבנייה שעמדה בפני המפקחת בהליך הקודם.

20. לטענת התובעים, מדובר באמרת אגב של כ' המפקחת צ. פיגנבויס שאין לגביה הכרעה עובדתית פוזיטיבית. לטענתם, עיון בפסקה 7(א) לפסק דינה של כ' המפקחת בהליך הקודם מלמד כי סוגיית הרחבת הדירה לא עמדה לדיון לפניו. פסק הדין אינו כולל הכרעה עובדתית פוזיטיבית כלשהי בנקודה הנתבעת על ידי הנתבע, וממילא אין הוא יכול להקים השתק פלוגתא כנגד התובעים. למעלה מן הצורך, וגם אם היה בפסק הדין בהליך הקודם משום קביעת ממצא פוזיטיבי, אין בו כדי להקים השתק פלוגתא נגד התובעים, משום שמדובר לכל היותר בממצא שבגררא, שהינו אגבי ובלתי חיוני.

21. התנאים לקיומו של השתק פלוגתא הם ארבעה: הפלוגתא הינה אותה פלוגתא בכל אחת מההתדיינות, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים; התקיימה התדיינות בין הצדדים באותה פלוגתא במסגרת ההתדיינות הראשונה, ומכאן שבעל הדין שנגדו מועלית טענת ההשתק היה לו יומו בבית המשפט ביחס אליה; ההתדיינות הסתיימה בהכרעה - מפורשת או מכללא - של בית המשפט, והממצא שנקבע הוא ממצא פוזיטיבי, להבדיל מממצא הנובע מהיעדר הוכחה; ההכרעה הייתה חיונית לצורך פסק הדין שניתן בתביעה הראשונה (ראו ע"א 2466/66 קלוזנר נ' שמעוני, פ"ד כב (2), 561; רע"א 5138/18 עוואד נ' עז"ד נפתלי נשר (פורסם בנבו, 16.10.2018) (להלן: "פרשת עוואד")).

22. אבחן להלן האם מתקיימים התנאים האמורים.

23. בשנת 2015 הגישו בעלים של 3 דירות בבית תביעה כנגד בעלים של שתי דירות אחרות בבית: ה"ה אופיר וה"ה שמעון, בגדרה עתרו למתן צו מניעה שיאסור על הנתבעים לבנות שני גרמי מדרגות חיצוניים, אחד לכל דירה, שיצרו כניסה חדשה לדירות אלו מהטעם שיהיה בבניית גרמי מדרגות אלו כדי לגרום להם לפגיעה מהותית כתוצאה מפגיעה בפרטיות, חסימת אור ואויר, הסבת רעש ועוד.

24. בסעיף 5 לפסק הדין בהליך הקודם מצינת כ' המפקחת כדלהלן: **"קודם שאדון בטענות הצדדים אוסיף כי הבניה המתוכננת על ידי הנתבעים כוללת גם הרחבת הדירות על דרך של בניית ממ"דים מעל הממ"ד של טואף, וכן בניית מרפסות זיזיות. זכותם של הנתבעים להרחבה זו אינה שנויה במחלוקת".**

25. נעלה מכל ספק, כי, למצער, שני תנאים מבין התנאים הנחוצים לקיומו של השתק פלוגתא לא מתקיימים בענייננו (המדובר בתנאים מצטברים): בתביעה בהליך הקודם **לא התבקש** למנוע את תוספת הבנייה בדירות אופיר ושמעון, לרבות בניית הממ"ד והמרפסת הזיזית אלא רק את בניית גרמי המדרגות, ומשכך אין השתק פלוגתא שכן כלל לא הייתה קיימת פלוגתא לגבי רכיבי בנייה אלו; היות שהתובעים בהליך הקודם לא העלו טענות כנגד רכיבי בנייה אלו במסגרת פסק הדין גם לא ניתנה הכרעה בעניינים אלו. לטעמי, אמרת המפקחת בסעיף 5 לפסק דינה אינה מהווה הכרעה וגם לא הכרעה בגררא כי אם ציון העובדה שזכות הנתבעים לבנות תוספת בנייה הכוללת ממ"ד ומרפסת לא הייתה חלק מהמחלוקת שהתבררה לפניו.

26. נמצא, אם כן, כי המפקחת אשר דנה והכריעה בהליך הקודם ציינה מפורשות כי השאלה שעמדה לדיון בפניה היא **רק** זכותם של הנתבעים שם לבנות את גרמי המדרגות החיצוניים, באשר זכותם של הנתבעים שם לבנות את הממ"ד והמרפסות הזיזיות לא היתה שנויה במחלוקת, קרי התובעים בהליך הקודם לא התנגדו ליתרת הבניה מושא האישור בתנאים שניתן לנתבעים שם. משעה שלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/53/2020
מס' בקשה: 8/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הייתה מחלוקת בנוגע לממ"ד ולמרפסת, וזו לא התבררה ולא נמצא לגביה ממצא פוזיטיבי פשיטא שאין מדובר בעניינו בהשתק פלגותא.

27. נשאלת השאלה האם חל בענייננו השתק עילה על פי הכלל הקובע כי מקום בו יכול היה התובע לרכז את כל העובדות והטענות הנוגעות למעשה במסגרת ההתדיינות הראשונה, תיחשבה שתי התובעות כנסמכות על עילות זהות באופן שמשעה שבחרו להעלות טענות מסוימות ולא אחרות, ומשעה שבית המשפט דן בכלל הטענות שהעלו והכריע בהן, אין כל הצדקה לקיים בירור נוסף שמטרתו להכריע בטענות משפטיות שהמבקשים בחרו שלא להעלות במסגרת התובענה.

28. אקדים את המאוחר ואציין כבר עתה כי לא מצאתי כי מדובר על אותה עילה שעה שמצאתי, כפי שיפורט להלן, כי התוכנית שהגיש הנתבע שונה מתוכנית הבניה מושא ההליך הקודם.

29. לאור האמור, לא מצאתי כי קיים השתק עילה לגבי תביעה זו.

30. אני משאירה בצריך עיון את השאלה האם היה חל השתק עילה כלפי התובעים שהיו צד גם להליך הקודם בהינתן שתוכנית הבניה הייתה זהה.

שיעור ההסכמות הדרוש לבניה-

31. בין רכיבי הבנייה מושא ההליך נכללת הרחבת דירת הנתבע לרבות באמצעות בניית מרפסת זיזית ושיפור מיגון לדירה.

32. הוראות הדין בגדרן מוסדרת זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו תוך מימוש זכויות בניה קבועות בסעיפים 71א-ד לחוק המקרקעין, בסעיף 71א מוגדרת הרחבת דירה כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף". סעיף 71ב(א) מתנה את הזכות להרחבת דירה אגב מימוש זכויות בניה בשני תנאים מצטברים:

"רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה". בהמשך, הסעיף מקל בדרישה ומורה כי "ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות."

33. הוראת החוק דנא החליפה את המצב המשפטי שקדם לה, לפיו רק בהסכמה של כל בעלי הדירות ניתן היה לבצע בניה ברכוש המשותף, ראו סעיף 62(א) לחוק המקרקעין וכן סעיף 2 (א) לתקנון המצוי.

34. המחוקק היה ער לקושי הנעוץ בכך שאוסף של פרטים, שכולם משיאי אינטרס עצמי, שהשאת האינטרס העצמי שלהם מחייבת שיתוף פעולה, עשויים - בהיעדר כפייה משפטית - לא להצליח לאחד כוחות על מנת להשיג את מטרותם. על כן במצבים שקידום האינטרס המשותף מחייב בהם השתתפות של כולם, צפוי שפרטים ינסו לנצל את עמדת המיקוח המיוחדת שהצורך בהשתתפותם מקנה להם, על מנת לנסות לגרוף לכיסם הפרטי חלק גדול ככל האפשר מהיתרונות ששיתוף הפעולה הקבוצתי עתיד להצמיח. לאור זאת סעיפים 71א-ד, ובדומה להם תיקוני חוק אחרים בחוק המקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/53/2020
מס' בקשה: 8/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(כדוגמת סעיף 59ג הדן בהקמת מעלית משותפת ברכוש המשותף), ביטלו את זכות הוטו שהייתה נתונה לכל מיעוט בבית וקבעו כי מלכתחילה יהא דרוש רוב מופחת תוך הוספת תנאים ואיזונים (כגון : תשלומי איזון, שמירת הזכות לבנות סוכה, זכות ההתנגדות של מי שנפגע מהותית מהחלטה כאמור וכו') ראו ח. דגן קניין על פרשת דרכים 405, 415 (2005). ראו גם ע"א (מחוזי חי) 1725/05 דוד נ' נברוצקי, פסקה 7 (פורסם בנבו, 30.3.2006) לאמור :

"תיקון 18 לחוק המקרקעין ביקש כעולה מדברי ההסבר שפורסמו בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף) תשנ"ה-1994, לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, בגדר הגמשה מסוימת של הדין בענין זה ששרר עד אז, בגדרו בניה על רכוש משותף לטובת בעל דירה היתה טעונה הסכמת הכל (ראה למשל ע"א 2111/03 פליצ'יה ואח' נ' סופיוב ואח' פסק דין מ-22.3.05 תק-על 3589(1)2005). תכלית התיקון היתה לאפשר הרחבת דיור תוך הפחתת כוחו של המיעוט למנוע אותה בגדר מגמה כללית לאפשר ניצול טוב יותר של הקרקע. התיקון נועד לאפשר לבעל דירה המשיג הסכמה של לפחות 3/4 מבעלי הדירות (כולל הדירה נשוא ההרחבה) שיש להם לפחות 2/3 מן הרכוש המשותף לבצע הרחבה בדירתו (סעיף 71ב' של חוק המקרקעין). סימן ג'1 לחוק המקרקעין שיוחד לענין שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה כולל בחובו איזונים שונים הבאים להבטיח כי הפגיעה בבעלי דירות המיעוט לא תהיה מעבר לנדרש (ראה בענין זה בספרו של המלומד מיגל דויטש, קנין חלק א' תשנ"ז-1997)....".

35. בע"א 1415/00 (מחוזי י-ם) אברהם נ' אזור, פסקה 8 (לא פורסם, 4.7.2001) התייחס בית המשפט באופן ספציפי לשאלה האם ניתן לראות בבניית מרפסת "הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין וכך נקבע בפסק הדין :

"...אין רמז לכך שהרחבה לא יכולה להתייחס לבניית מרפסת שהרי כבר נפסק שמרפסת היא חלק מדירה. בע"א 190/84 דיבון נ' הממונה על המרשם, פ"ד תשמ"ה(ב), 265, פסק כב' הנשיא זילר, כי אין מניעה שדירה תכלול גם שטח בלתי מקורה. (לדיון בפסיקה זו ראו: י. ויסמן, בספרו הנ"ל, עמ' 384-379)". באופן דומה הבהיר זאת גם המלומד אייזנשטיין, בקובעו: "במונח הרחבה, נכללת כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה...ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה...התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש..."

וכן ראו א. אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי: בתים משותפים 223 (2001).

36. הנה כי כן, שיעור ההסכמות הדרוש לצורך בניית מרפסת זיזית הוא 75% מבעלי הדירות בבית שצמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף.

37. לעניין שיעור ההסכמות הדרוש לצורך בניית ממ"ד מורנו סעיף 71ב(א) לחוק כי די בהסכמת 60% מבעלי הדירות בבית. נשאלת השאלה מה דינה של תוספת בנייה שנבנית בדירת הנתבע כשיפור מיגון שנעשה בדירתו.

38. הנתבע טען כי תוספת הבניה שנבנית בדירתו היא בתמורה לשיפור מיגון שהוא מבצע בחדר בדירה ועל כן ביקש להחיל לגביה את הרוב הדרוש שנקבע בסעיף 71ב(א) לגבי בניית ממ"ד, קרי, הסכמות בשיעור של 60%. בתמיכה לטענתו הפנה הנתבע לפסק דין שניתן על ידי בתיק (המפקח על רישום מקרקעין חי) 87/11 גבריאלי נ' בוזגלו (פורסם בנבו, 07.12.2011) (להלן: "פרשת גבריאלי").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/53/2020
מס' בקשה: 8/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. התובעים טענו כי שיפור מיגון אינו ממ"ד ועל כן לא חל על בנייתו שיעור ההסכמה המופחת שנקבע לגבי בניית ממ"ד.

40. במחלוקת דנא דעתי כדעת התובעים, וזאת לאור קביעת בית המשפט המחוזי בעש"א (מחוזי ת"א) 61803-03-15 דסטגר נ' גלברג (פורסם בנבו, 2.12.2015). באותו תיק התבקש לבצע שיפור מיגון בדירה בבית ולבנות בזכויות הבניה שניתנו בתמורה לשיפור מיגון תוספת בניה, וקבע בית המשפט כי נדרשת הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית לבניה, וכך נקבע בפסק הדין :

"אינני מקבלת את טענת המערערים כי על המקרה חלה הסיפא של סעי' 71ב(א) ולכן הרוב הנדרש לעבודותיהם הוא 60% מבעלי הדירות. בענייננו אין מדובר ב- " הרחבת דירה... לשם בניית מרחב מוגן דירתי" כלשון החוק, אלא בחיזוק החדר הקיים שבדירת המערערים, ובנוסף לכך מדובר בהרחבת דירת המערערים לעבר הגג, דהיינו גם בנייה בגג, שהוא רכוש משותף. לפחות באשר לבנייה בגג שאליו אמורות להוביל מדרגות פנימיות, ברי שיש צורך בהסכמה הרחבה יותר של 75% מבעלי הדירות. יתר על כן, לפי סעי' 197(א)(3) ו- 201(ג) לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990, החדר המחוזק שבבקשת המערערים אינו מהווה ממ"ד לפי הדין. החדר הנדון הוא בקומה העליונה של הבניין, קומה 3, אין מתחתיו מגדל ממ"דים עד ליסודות הבניין, וכן 75% מקירותיו ההיקפיים אינם מחוברים ליסודות הבניין לכל גובה הבניין".

41. פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוא פסק דין מנחה (המאוחר לפסק דיני הנ"ל) ולאורו קובעת אני כי תוספת בניה מכוח זכויות אשר מוקנות בתמורה לשיפור מיגון מהווה "הרחבת דירה" שנדרש לקבל לגביה הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית שצמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף.

42. לאור האמור, נמצא כי לכל רכיבי הבניה בדירת הנתבע נדרשת הסכמה בשיעור של 75% מבעלי הדירות בבית שצמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף.

שיעור ההסכמה שהתקבלה לבנייה של אופיר-

43. מעיון בטופס ההסכמות עליו חתמו בעלי הדירות בבית לצורך היתר הבניה שהתבקש על ידי אופיר, צורף כנספח א' להודעת הנתבעים מיום 10.5.20, עולה כי 4 בעלי דירות (תתי חלקות 2, 3, 6, 9 נתנו את הסכמתם) לבניה שהתבקשה על ידו.

44. שמעון סימה, אשר בבעלותה תתי חלקות 7 ו-8, הגישה בקשה להיתר בנייה בשנת 2013 בצוותא חדא עם אופיר. אין חולק על כך שאופיר ושמעון לא חתמו על טופס ההסכמה לבנייה, עם זאת, נהיר כי אופיר ושמעון שהגישו בקשה משותפת להיתר בנייה מוחזקים כמי שמסכימים זה לבקשתו של זה אף מבלי שצרפו את חתימתם לטופס ההסכמות. הנה כי כן, יש לראות גם את דירות 7 ו-8 כמי שנתנו את הסכמתם לבנייה של אופיר.

45. להסכמות אלו יש להוסיף את הסכמת אופיר בעצמו.

46. סיכום האמור, מביא לכך ש-7 מ-9 בעלי דירות בבית נתנו הסכמתם לבנייה של אופיר מה שמהווה הסכמה של 77.7% מבעלי הדירות בבית אשר צמודים להם למעלה מ- 2/3 מהרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/53/2020
מס' בקשה: 8/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. מן האמור עולה כי היקף ההסכמות שקיבל אופיר לבנייה שהתעתד לבנות מילאה אחר דרישות סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין.

האם יש לראות בהסכמות אלו כהסכמה גם לתכנית אותה הגיש הנתבע-

48. במסגרת ההליך שנוהל לפניי לא הגיש מי מהצדדים להליך את תוכנית הבקשה להיתר בניה של הנתבע. על אופייה של הבניה יכולתי לעמוד רק מתוך נספח לכתב ההגנה הנושא כותרת "חשובים סטטיים" אשר מכיל קטע מתוכנית הבניה של הנתבע. מהשוואת תכנית היתר הבניה של אופיר לקטע התוכנית של הנתבע עולה כי אמנם קונטור שתי ההרחבות זהה אך בעוד שבתוכנית של אופיר תוכנן ממ"ד מעל הממ"ד שבדירה תחתיו, היא דירת טואף, בתוכנית של הנתבע מתוכנן חדר רגיל מעל הממ"ד בדירת טואף, ובמיקום אחר בשטח ההרחבה מודגם חדר קיים בדירה המקורית הנושא כיתוב "שיפור מיגון מוצע".

49. היות שלא צורפה, כאמור, הבקשה להיתר בנייה של הנתבע ולא היה נהיר מהחלטות מוסדות התכנון האם בקשת אופיר ובקשת הנתבע זהות (למעט המדרגות החיצוניות), חיפשתי מענה לאמור בטענות הצדדים. בסעיף 6 לסיכומי התובעים מציינים התובעים בעניין כדלהלן: **"יצוין כי חרף העובדה כי הבקשה להיתר כוללת 'שיפור מיגון', הרי שלא מדובר בבניית 'ממ"ד' ולכן גם לגבי רכיב זה בבקשה להיתר נדרשת הסכמה של 75% מבעלי הדירות שלהן צמוד 2/3 מהרכוש המשותף..."**

הנתבע אינו מכחיש בסיכומיו את טענת התובעים כי בקשת היתר הבניה שלו כוללת "שיפור מיגון" חלף ממ"ד אלא טוען כי: **"כאן המקום להוסיף כי בהתייחס לאמור בסעיף 6 לסיכומי התובעים. הרי שבמקרים מסוימים, כבענייננו, בנסיבותיו, הרי שיש בשיפור המיגון להוות תחליף לממ"ד"**

50. מהאמור עולה כי התוכנית שהגיש הנתבע אמנם מתוכננת באותו קונטור, קרי, מנצלת את מלוא גג תוספת הבניה בדירת טואף, בדומה לתוכנית הבניה של אופיר, אך אין מדובר בבקשה לחידוש בקשת הבניה שהגיש אופיר, ואף לא בתוכנית הזוהה לה, כי אם בתוכנית חדשה שאינה זוהה לתוכנית שהגישו אופיר. השוני בין התוכניות אינו מתבטא רק בהסרת המדרגות החיצוניות שתוכננו ע"י אופיר (אשר בעניינן ניתן צו מניעה), אלא בתכנון חדר שיפור מיגון חלף הממ"ד אשר תוכנן להיבנות בדירת אופיר מעל הממ"ד שנבנה בדירת טואף, ובמיקום שונה.

51. בהינתן כי מדובר בתוכנית בנייה שונה מתוכנית הבניה של אופיר לא ניתן לומר כי ההסכמות שנתנו בעלי הדירות בבית מחייבות אותם גם ביחס לתוכנית בניה זו.

52. ויטעם, אין מדובר בשינויים מינוריים. לשינוי תוכנית הבניה יכולות להיות השלכות על בעלי הדירות בבית. לדוגמא, השינוי האמור יכול להשליך על דירת שמעון, המצויה מעל דירת הנתבע, שלא תוכל לבנות בעתיד ממ"ד בדירתה שכן ממ"ד נבנה במגדל ממ"דים אשר יורד עד לקרקע, כך שבניית חדר רגיל מעל הממ"ד בדירת טואף "קוטעת" את רצף הממ"דים ועלולה לסכל אפשרות של בניית ממ"ד בדירת שמעון.

53. מששינה הנתבע את תכנית הבניה שהוגשה על ידי אופיר אין הוא יכול לטעון כי "נכנס בנעליו" של אופיר וכי הסכמת בעלי הדירות שניתנה לאופיר מחייבת גם כלפיו או כי הסתמך עליהן ועל האמור בפסק הדין שניתן בהליך הקודם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/53/2020
מס' בקשה: 8/54/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

54. ודוק, אפילו בעלי דירה שנתנו הסכמתם לבניה אינם מחויבים מכוח ההסכמה שנתנו שעה שמהבניה לה הסכימו עוברת שינוי מהותי. לא כל שכן, שבעלי דירה שנתנו הסכמות לבניה אינם מחויבים כלפי בעל דירה חדש שעה שהבניה השתנתה.

וראו בעניין את הדברים שנקבעו בעש"א (מחוזי חי') 43812-02-18 שחיבר נ' בולוס (פורסם בנבו, 10.07.2018) ע"י כב' השופט רניאל :

"אני דוחה את טענות המערערים כנגד קביעתה של המפקחת, כי הסכמת כרמון לבנייה קודמת אינה מחייבת את המשיבים 6-7, ואינה נחשבת כהסכמתם לבנייה. המיקום של הממ"דים הוא הנושא שבמחלוקת בין הצדדים. כפי שקבעה המפקחת, כרמון הסכימו לבקשת המערערים לבניית ממ"דים בבקשה 06, שעסקה במיקום שונה. כרמון לא הסכימו לבקשת המערערים לבניית ממ"דים בבקשה 08, בצד המזרחי שהיא הנדונה כעת. בעת הגשת בקשה זו, כבר לא היו בעלי הדירה, אלא המשיבים 6-7 שדם הם לא הסכימו לבקשה 08. על כן, בדין קבעה המפקחת, שהסכמת כרמון לבקשה קודמת במיקום שונה אינה מחייבת את המשיבים 6-7 ואין בידי המערערים הסכמה מטעם בעלי דירה זו".

55. בנסיבות אלו לא מצאתי להידרש לשאלה האם רשאים היו התובעים לחזור בהם מההסכמות שנתנו לאופיר לאחר שהאחרון מכר את דירתו לנתבע או בשל חלוף הזמן ממועד מתן ההסכמות ועד למכירת הדירה, כמו כן, איני מוצאת להרחיב הדיון מעבר לאמור לעיל בשאלה האם הנתבע רשאי היה לטעון להסתמכות על הסכמות אלו.

האם ההתנגדות לנתבע מהווה התנגדות שלא בתום לב-

56. הנתבע טען כי התנגדות התובעים סתמית וקנטרנית. לטענתו, התובעים לא הצביעו על האופן שבו תיפגע דירה כלשהי מבניית הנתבע. טענתם היחידה של התובעים כי הבנייה תסכל אפשרות של ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית אשר נטענה מן השפה אל החוץ. ולראיה התובעים כלל לא החלו לפעול לקידום פרויקט תמ"א 38. לחיזוק טענתו, הפנה הנתבע לדברים שנקבעו על ידי בפרשת גבריאלי.

57. התובעים טענו כי העובדה שנתנו הסכמה לאופיר לבנות אך סרבו לבניית הנתבע אינה מהווה התנגדות שאינה בתום לב שכן במרוצת השנים מאז נתנו הסכמתם לאופיר התיישן הבית ומרבית בעלי הדירות בבית מעוניינים לבצע פרויקט תמ"א 38 בבית. לטענתם, הסכמתם לבעל דירה אחד אינה מחייבת אותם להסכים גם לחליפו. בעניין זה הפנו התובעים לדברים שנקבעו בעש"א (מחוזי ת"א) 2016/09 זלצר נ' הולצמן, (פורסם בנבו, 27.12.2010) כדלהלן :

"שיקוליהם של המשיבים שנתנו הסכמה להרחבה לשכניהם האחרים אין בה כדי לחייב אותם להמשיך ולפגוע בזכויותיהם הקנייניות, שהרי הרוב רשאי לאשר הרחבה לא' ולא לאשר הרחבה לב', אולם הרוב אינו רשאי לאשר הרחבה לא' על חשבון ב' תוך קיפוחו (אייזנשטיין, בעמ' 234), מה שאין כן בענייננו."

58. לא מצאתי לגזור גזירה שווה מהדברים שנקבעו על ידי בפרשת גבריאלי לענייניו כאן. בפרשת גבריאלי נבחנה על ידי רצינות הטענה כי הבניה תסכל ביצוע פרויקט תמ"א 38 בהיבט של חזרה מהסכמה, ואילו כאן לא מצאתי כי הנתבע קיבל הסכמות לבניה. לדידי, יש לבחון באופן נוקשה יותר את הסיבות לחזרה מהסכמה מאשר הסיבות לאי מתן הסכמה מלכתחילה, באשר במקרה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מס' תיק: 8/53/2020
מס' בקשה: 8/54/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הראשון מסתמך מקבל ההסכמה על ההסכמה ואפשר שאף שינה בעטיה מצבו לרעה, ואילו במקרה השני בו מועלית טענת התנגדות מלכתחילה ספק אם יש מקום לטעון להסתמכות או לשינוי מצב לרעה.

59. בעניין החזרה מהסכמה נכון יותר לטעמי להפנות לעש"א (מחוזי חי') 17181-05-11 נגד נ' פדאל (פורסם בנבו, 20.02.2011) שם צומצמה סמכותו של בית המשפט בבחנו את נימוקי ההתנגדות, וכך נקבע בו:

"בשאלה הראשונה שהיא עקרונית, אם לאור האמור בסעיף 71 לחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה" עומדת הזכות למתנגד שלא לפרט את נימוקי להתנגדות, אפילו אלה סתמיים ואפילו נוגדים הם את עקרונות שיטת המשפט ותום הלב- שהוא אחד מעקרונות היסוד בשיטה- סבורה הייתי וסבורה אני שאין לאפשר התנגדות ללא הנמקה.

בשלב השני שלאחר הבאת הנימוקים סמכותו של ביהמ"ש לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר. אכן, אין לדעתי לאפשר התנגדות סתמית שאינה עניינית או שיש בה משום שימוש לרעה בזכות הקניין, כך נאמרו על ידי בפס"ד צבי והוספתי כדוגמא כאשר בעלים של מספר דירות בבניין מתנגדים מתוך כוונת קנטור או בשל "מוצא או נסיבות אחרות הנוגדות את עקרונות שיטת המשפט ואשר אין בהם דבר או חצי דבר עם הפגיעה הקניינית לכשעצמה..."

וראו גם הסקירה שניתנה על ידי בתיק (מפקח על רישום מקרקעין חי') 33/13 הולנד נ' יקים (פורסם בנבו, 21.12.2013), וכן את הדברים שנקבעו בעש"א (מחוזי חי') 42061-03-16 לוי נ' נגרי (פורסם בנבו, 25.7.2016):

"כב' המפקחת הייתה ערה לטיעון הנ"ל של המערערים ולהחלטתה דלעיל של ועדת הערר, אך בצדק קבעה, כי אין לשלול את האפשרות שהבנייה שהמערערים מבקשים לבנות, הכוללת בניית חדר, חדר שירותים וממ"ד, תימצא ותוגדר כ"בנייה שאינה מינורית אשר יש בה כדי לסכל אפשרות לבנייה לפי תמ"א 38".

נימוק התנגדות זה הינו סביר ונוסיף, כי ערים אנו לכך שהמערערים הצהירו ומוכנים להצהיר שהם יהרסו את תוספת הבנייה המבוקשת על ידם, ככל שיעמוד על הפרק ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין, אך עדיין אין בהצהרה זו כדי להבטיח שתוספת הבנייה המבוקשת כיום, לא יהא בה כדי לסבך בעתיד את האפשרות למימוש פרויקט תמ"א 38 בבניין נשוא הדיון."

60. סיכום האמור מעלה כי ככלל נתונה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לבחון את נימוקי ההתנגדות, וכי התנגדות שאין נימוקים בצידה לא תתקבל. יחד עם זאת, נקבע בפסיקה כי יש לצמצם סמכות זו, קרי, למפקח על רישום מקרקעין לא קיימת הסמכות לשקול חלף בעלי הדירות את שיקוליהם ולבטלם מקום בו דעתו שונה מדעתם.

61. הנתבע טען כי אין ממש בטענת התובעים כי הם מעוניינים לבצע תמ"א 38 בבית, ולראיה הם לא החלו לקדם תכנית כלשהי או לפנות לקבלנים. התובעים טענו כי קבלנים אליהם פנו אינם מסכימים לקדם תמ"א 38 בבית כל עוד תתכן אפשרות שהנתבעים ירחיבו דירותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/53/2020
מס' בקשה: 8/54/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

62. כפי שפורט לעיל, משוויתרו הצדדים על קיום דיון הוכחות והמצהירים לא נחקרו על תצהיריהם אין בידי לקבוע כל ממצא באשר למהימנות ההצהרות שהוגשו, ואין בידי לשלול את טענת התובעים באשר לרצונם לקדם תמ"א 38 בבית.

63. לאור האמור, לא מוצאת אני לקבוע כי התנגדות התובעים מהווה התנגדות שלא בתום לב.

סוף דבר-

64. התביעה מתקבלת. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים או על מי מטעמם לבנות בהתאם להיתרי הבניה כל עוד לא תהיה בידיהם הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית בהיקף הנדרש.

65. אני מחייבת את הנתבע מס' 1 בהוצאות התובעים, ביחד ולחוד, בסך כולל של 7,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (20.1.20) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן בהיעדר הצדדים ביום ז' בכסלו תשפ"א (23.11.20)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין